

<제14장 쟁의행위.제10절 쟁의기간 중 대체근로의 제한>

I. 의의 및 취지[노조법 제43조 제3항·제4항]

- 쟁의행위 기간 중 대체근로의 제한이란 사용자가 노동조합의 쟁의행위(파업 등)로 인해 중단된 업무를 수행시키기 위하여 새로운 근로자를 채용하거나 기존의 비조합원 근로자를 총원하는 행위를 법으로 제한하는 제도를 의미한다. 이러한 제한은 헌법 제33조에 보장된 근로자의 단체행동권의 실효성을 확보하는 데 그 주요 취지가 있다. 사용자가 자유롭게 대체근로를 활용할 수 있다면 쟁의행위의 효과가 무력화되어 노동조합의 교섭력이 현저히 약화될 수 있기 때문이다. 이 제도는 노사 간의 힘의 균형을 맞추고 쟁의행위가 평화적으로 해결될 수 있도록 압박하는 역할을 수행한다.

II. 대체근로 등의 제한

1. 사업과 관계없는 자의 대체금지[노조법 제43조 제1항]

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제43조 제1항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 그 쟁의행위로 중단된 업무를 수행하기 위하여 그 사업과 관계없는 자를 채용 또는 대체하는 것을 금지한다.

(1) 사업과 관계없는 자

- 사업과 관계없는 자란 쟁의행위가 발생한 사업장의 소속 근로자가 아닌 자를 의미하며, 신규 채용 근로자, 파견 근로자, 다른 사업장의 소속 근로자 등이 이에 해당한다.

(2) 채용 또는 대체

- 채용은 신규 고용을 의미하며, 대체는 새로운 근로자를 투입하거나 파견받는 행위를 의미한다.

2. 채용·대체의 허용범위

(1) 허용되는 대체근로

- 쟁의행위에 참가하지 아니한 근로자는 동일한 사용자의 다른 사업장 소속이거나 해당 사업장 소속이라면 원래 담당했던 업무 외에 쟁의행위로 중단된 업무에 투입될 수 있다. 즉, 기존의 근로자를 재배치하여 활용하는 것은 허용된다.

(2) 금지되는 대체근로

- 사업장 밖에서 외부 인력을 신규로 채용하거나 파견받아 중단된 업무에 투입하는 행위는 엄격히 금지된다.

3. 도급 등의 금지[노조법 제43조 제2항, 파견법 제16조 제1항]

(1) 도급 및 하도급의 금지

- 노조법 제43조 제2항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 그 사업과 관계없는 자에게 도급 또는 하도급을 주어 중단된 업무를 수행하게 하는 것을 금지한다. 이는 직접적인 대체근로 금지 규정의 회피를 막기 위함이다.

(2) 근로자 파견의 금지

- 파견근로자보호 등에 관한 법률(이하 '파견법') 제16조 제1항은 쟁의행위 중인 사업장에 파견근로자를 투입하거나 대체하는 것을 금지한다.

III. 필수공익사업에서 일부 대체근로의 허용

1. 의의[노조법 제43조 제4항]

- 필수공익사업의 경우, 쟁의행위로 인한 업무 중단은 공중의 생명·건강 또는 국민의 일상생활에 막대한 영향을 미칠 수 있다. 이에 노조법 제43조 제4항은 필수공익사업의 사용자에게 한하여 노조법 제43조 제1항의 대체근로 제한 규정을 완화하여 일부 대체근로를 허용한다.

2. 필수공익사업의 범위[노조법 제71조 제2항]

- 필수공익사업은 노조법 제71조 제2항에 규정되어 있으며, 주로 공중의 일상생활에 필수적인 기능을 수행하는 사업이다. ① 철도사업, 도시철도사업. ② 항공운수사업, 육상화물운송사업 중 국가경제 및 국민생활에 중대한 영향을 미치는 사업. ③ 수도, 전기, 가스, 열 공급 사업. ④ 병원사업, 혈액 공급 사업. ⑤ 한국은행 사업 등이 이에 해당한다.

3. 대체근로자수의 제한[노조법 제43조 제4항, 노조법 시행령 제22조의4, 파견법 제16조 제1항]

(1) 대체근로자수의 제한

- 필수공익사업의 사용자라 하더라도 무제한적인 대체근로가 허용되는 것은 아니다. 노조법 제43조 제4항 및 노조법 시행령 제22조의4에 따라 대체근로자는 쟁의행위로 중단된 업무의 정상적인 운영을 위해 필요한 최소한의 인원수로 제한된다. 구체적으로 당해 사업 또는 사업장 파업참가자의 100분의 50을 초과할 수 없다.

(2) 파견 근로자의 제한

- 파견법 제16조 제1항은 필수공익사업의 경우라도 근로자 파견을 통한 대체근로는 여전히 제한한다.

IV. 위반의 효과

1. 부당노동행위의 구성

- 사용자가 대체근로 제한 규정을 위반하여 쟁의행위 기간 중 사업과 관계없는 자를 투입하거나 도급을 주는 행위는 노동조합의 단결권 및 단체행동권을 침해하는 것으로 간주될 수 있다. 이는 노조법 제81조 제1호(불이익 취급) 또는 제5호(지배·개입)에 해당하는 부당노동행위를 구성할 수 있다.

2. 벌칙[노조법 제91조]

- 노조법 제43조 제1항·제2항·제4항의 대체근로 제한 규정을 위반한 자는 노조법 제91조에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 이는 쟁의권을 보호하기 위한 강력한 형사 처벌 규정이다.

V. 결론

- 쟁의기간 중 대체근로의 제한은 근로자의 헌법상 단체행동권을 실질적으로 보장하기 위한 핵심적인 제도이다. 원칙적으로 사업과 관계없는 자의 채용, 대체, 도급, 하도급은 엄격히 금지되나, 필수공익사업에 한하여 공익 보호를 위해 제한적인 범위 내(인원수의 50% 이내)에서 대체근로가 예외적으로 허용된다. 이러한 제한 규정을 위반하는 경우 부당노동행위는 물론 형사 처벌의 책임까지 수반하게 된다.